

1518043-37.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... a desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de furto tentado, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 162/165).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Vez que não houve apreensão de res furtiva, tanto a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518043-37.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518043-37.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216841/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 26659574 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2216841 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diogo Marques Machado De Oliveira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S.

DIOGO MARQUES MACHADO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c.c. art. 29, caput, por cinco roubos, na forma do art. 70, todos do Código Penal, porque no dia 09 de agosto de 2022, por volta de 18h, e em um salão de beleza, situado na Rua Manuel Borba, 194, Santo Amaro, nesta Capital, agindo em concurso ajustado de ações com outras duas pessoas não identificadas, subtraiu, para si e comparsas, mediante graves ameaças exercidas com emprego de arma de fogo, coisas móveis - consistentes em cinco telefones

celular das marcas Apple, Samsung e Motorola - pertencentes às vítimas Thayna Gonzaga da Silva, Ana Paula de Jesus Costa, Jamilly Araújo da Costa, Adailsa Santos França e Josiane Santos de Oliveira.

Segundo a denúncia, o acusado e os outros agentes ingressaram repentinamente no aludido salão de beleza, ocasião em que a comparsa do sexo feminino, portando uma arma de fogo, reduziu todos os presentes à impossibilidade de resistência mediante graves ameaças.

Ato contínuo, os agentes se apoderaram de um telefone celular Apple da funcionária Thayna Gonzaga da Silva, um celular Samsung da cliente Ana Paula de Jesus Costa, um telefone celular marca Apple da cliente Jamilly Araújo da Costa, um telefone celular marca Samsung da funcionária Adailsa Santos França, e por fim, um telefone celular marca Motorola da cliente Josiane Santos de Oliveira, ou seja, um total de cinco telefones celulares, cada um deles pertencente a uma vítima diferente.

Assim, em posse dos citados objetos, os três agentes rapidamente se foram em fuga. Ocorre que a Polícia Militar foi logo avisada, pelo que policiais militares passaram a diligenciar pelas imediações e, logo depois, e ainda pelas proximidades, encontraram e detiveram apenas DIOGO.

O acusado foi encaminhado ao 11º DP desta Capital, onde restou reconhecido em pessoa não apenas pelas tais cinco vítimas, como ainda por Maria José da Silva, que também estava no local quando dos fatos, acabou preso em flagrante.

O produto criminoso não restou recuperado, pois decerto levado pelos comparsas ainda não identificados.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 41/44.

A denúncia foi recebida em 22 de agosto de 2022 (fls. 94/96).

O réu foi citado, foi apresentada resposta à acusação (fls. 122/125) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 129).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as vítimas, testemunhas de acusação e comuns e, após, o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a procedência da ação para condenar o réu nos termos da denúncia (mídia digital).

A Defesa, por se turno, em sede de memoriais, argumentou com a existência de contradições da prova oral coligida nos autos. Postulou a desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de furto tentado, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 162/165).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Vez que não houve apreensão de res furtiva, tanto a materialidade como a autoria do delito surgem da prova oral coligida aos autos, bem como do Boletim de Ocorrência de fls. 29/32.

O réu, na fase inquisitiva, confirmou ter ingressado no estabelecimento e que teria tentado subtrair apenas dois equipamentos de cabelereiro, pretendia vendê-los, contudo, foi detido por policiais. Nega que tenha participado do delito praticado por outros indivíduos no estabelecimento, os quais subtraíram pertences das pessoas que lá estavam. Quando ingressou no local, eles já haviam se evadido (fls. 18/19).

Em seu interrogatório judicial, o acusado negou a prática dos delitos. Estava passando pelo local, encontrou os roubadores, foi fazer um furto junto, entrou depois que eles saíram para furtar dois cabelos, no começo da loja, e os policiais chegaram e disseram que ele estava roubando a loja. Não falou com o delegado. Tem 18 anos. Quando menor foi sindicado por ato infracional equivalente a furto, ficou um mês internado. Foi furtar de novo por causa da Covid-19 – embora os fatos tenham ocorrido em agosto de 2022. Viu um homem e uma mulher fazendo os roubos. Estava passando e viu todo mundo correndo do salão. Quando os roubadores saíram, foi tentar pegar os dois cabelos.

A versão do acusado, contudo, restou isolada no conjunto probatório produzido, e a ele incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima Thayna não conseguiu reconhecer o acusado em Juízo como autor do delito. Disse que trabalhava no salão, tinha descido para atender uma cliente, ela estava fazendo um Pix, uma moça pediu uma informação, sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo. Ela mesma veio recolhendo todos os celulares. Mandou irem para o fundo do salão, onde tem uma escada, sentiu uma mão lhe puxando, a pessoa falava "era você mesma", era um homem, subiu com ela as escadas. Havia uma moça comendo, Maria José. Ele lhe jogou na sala e ficava perguntando onde estava a dona do salão, disse que não sabia e ele lhe deu um tapa no rosto e ele foi perguntar para Maria José. Ele voltou e lhe deu outro tapa na cara, disse que não sabia. Ele deu um murro na boca do estômago, desfaleceu, e então ela veio e lhe disse que tinha chegado polícia. Os policiais já tinham detido um rapaz, que disse que pegaram dentro do salão. O rapaz que lhe agrediu era "moreno" e estava de máscara, não era o que foi preso. Só viu inicialmente a moça e o rapaz que lhe bateu. Subtraíram seu celular, acha que tinham 12 pessoas, levaram de todo mundo, mas nem todo mundo quis ir para a Delegacia de Polícia. Não precisou de atendimento médico.

A ofendida Ana Paula RECONHECEU o acusado em audiência e disse que estava no salão, cliente, e aguardava ser atendida, vieram uma mulher loira e dois rapazes, o réu e mais um e anunciaram o roubo. A moça tirou uma arma da cintura e mandou todo mundo entrar e pegar os celulares. Ela ficou com a arma e os rapazes pegaram os celulares. Acha que subtraíram cerca de cinco celulares, havia cerca de dez pessoas. Eles queriam roubar os cabelos do salão, mas a polícia chegou e eles correram, os policiais detiveram só o réu. Ficou no térreo do salão. Eles mandaram virar de costas e ficar parados de frente para a parede. Um deles subiu e ficaram embaixo o outro, não sabe qual, e a mulher com a arma. A mulher mandou pegar o celular e colocar no sofá, um deles pegou e colocou na cintura, mas também não sabe qual dos dois rapazes.

A vítima Jamilly não conseguiu reconhecer o acusado como autor do delito. Afirmou que no final dos crimes, sabe que a polícia chegou e todo mundo se jogou no chão. O réu foi preso no dia. O réu não era um dos dois homens que estava no salão. Ficou muito nervosa, ficou de costas como a roubadora mandou. Acha que todas as vítimas reconheceram, mas não viu o acusado, não sabe por que o delegado colocou que ela reconheceu também. Não viu o réu quando do roubo, lembra direitinho da mulher.

Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

"PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o

acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas, até porque não restou demonstrado nos autos qualquer indício que implicasse no descrédito das palavras das vítimas, havendo, por outro lado, certeza tanto em Juízo como na esfera policial quanto ao reconhecimento do acusado como autor do delito.

A testemunha Maria José da Silva RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito. Disse que é "tecista", costura cabelo. Estava em cima no local, o réu subiu e perguntou quem era a dona, disse que não tinha celular, subtraíram cabelos, que fazem peruca. Viu o rapaz "moreno" e o réu, mas não a mulher, que estaria com a arma de fogo. Os dois rapazes foram ao segundo andar. Estava sozinha no segundo andar, eles obrigaram Tainá a subir. Tainá disse que o "moreno" a agrediu, não o réu. Não sabe quantos celulares levaram, mas acha que foram três ou quatro. Eles desceram e continuou em cima. O acusado foi preso quando saía do salão, os outros correram e fugiram.

O Policial Militar Carlos Henrique de Lima Felício, reconhecendo o acusado em audiência, disse que estavam em patrulhamento quando foram avisados pelo COPOM do roubo, foram ao local e lá chegando o acusado tinha sido detido por populares. Ele foi detido na calçada do estabelecimento. Indagado, o acusado disse que estava praticando roubo com mais duas pessoas, uma mulher armada e outro rapaz. Eles fugiram, não estavam no local quando chegaram. Ele disse que tinha subtraído "dois cabelos". Com ele não havia nada das vítimas. Os cabelos estavam no salão. Houve cinco vítimas do roubo de celular. Falaram no local que a mulher usava arma de fogo, ela se chamaria "Emily". Ele negou estar armado, disse que a "Emily" estava, mas o outro rapaz ele não conhecia.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...)

CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

Os roubos restaram, assim, consumados, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

E a jurisprudência:

"Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se consumado o delito de roubo "no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 118.407/ SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada" (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

"O crime de roubo está consumado se o agente, ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a disponibilidade dos objetos. Não é exigível a posse tranquila da res furtiva, bastando que cesse a violência ou a clandestinidade" (STJ/EResp/DF 197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

De rigor o reconhecimento das majorantes do emprego da arma e do concurso de agentes, vez que descritas pelas vítimas e testemunhas.

Ademais, consoante já decidiram o C. STJ e o E. TJSP, não é necessário para o reconhecimento da causa de aumento de pena do roubo consistente no uso de arma de fogo a apreensão ou perícia dela:

"PROCESSO PENAL (...) Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos das vítimas, que efetuarão reconhecimento pessoal - Validade - Negativa isolada - Suficiência para a procedência da ação penal - Condenações mantidas - Causa de aumento do emprego de arma - Manutenção. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Causa de aumento do concurso de agentes. Manutenção. Palavra das vítimas, que foi explícita ao mencionar que os recorrentes agiram em conluio com, ainda, outros indivíduos. Pena. Elevação da pena base pelas circunstâncias do delito. Regime prisional fechado mantido. Delito praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo. Roubo circunstanciado. Apelo ministerial. Dosimetria. Agravamento da reprimenda. Circunstância judicial. Pena-base fixada acima do mínimo. Insuficiência. Gravidade da conduta que justifica a elevação pela metade. Concurso de agentes e emprego de arma. Acréscimo de 3/8. Causas de aumento bem dosadas. Apelo ministerial parcialmente provido."(TJSP - APL nº 0.001.195-52.2004.8.26.0334 - Ac. 5.257.920 - Monte Aprazível - 16ª Câ. de Direito Criminal - Rel. Des. Almeida Toledo - J. 12.07.2011 - DJESP 30.08.2011)-grifei.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Inafastável, assim, a condenação do acusado por infração ao art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por cinco vezes na forma do art. 70, ambos do Código Penal, vez que praticados mais de um delito contra cinco vítimas distintas, mediante uma só ação; inexistindo meios para a pretensa desclassificação para o delito de furto tentado. Ora, a despeito das alegações da defesa, restou suficientemente demonstrado nos autos, sobretudo pelo reconhecimento em Juízo da vítima Ana Paula e da testemunha Maria José, bem como pelas declarações das vítimas e testemunhas colhidas durante a instrução, que o acusado praticou os delitos de roubo descritos na denúncia em concurso de agentes com um rapaz e uma mulher, mediante emprego de arma de fogo e violência, esta empregada especialmente contra a vítima Thayna. Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O acusado é primário e menor de 21 anos (fls. 33/34 e 92/93).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Deixo de atenuar a pena em razão da menoridade relativa do acusado à época dos fatos, por ter fixado a pena-base no mínimo legal (Súmula nº 231 do C. STJ).

Não há agravantes a serem consideradas.

Pela causa de aumento do roubo – concurso de agentes –, de rigor a exasperação da pena em 1/3, totalizando cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Ademais, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/2018, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

Adoto tal coeficiente de aumento de pena por expressa determinação legal (Lei nº 13.654/2018), bem como a fim de não equalizar situações desiguais, ainda mais em delitos violentos, pois, no presente caso, o roubo foi praticado mediante duas majorantes, que denotam elevada reprovabilidade da conduta, na medida em que implicam temor demasiado às vítimas e reduzem a possibilidade de pronta reação. Isso porque, restou demonstrado que as vítimas foram subjugadas pelo acusado e seus comparsas, unidos em comunhão de desígnios e armados, para ameaçá-las e intimidá-las, bem como agredi-las (vítima Thayna) e, assim, impedir/reduzir a possibilidade de reação e facilitar a subtração dos bens que almejavam, tudo visando ao êxito da empreitada criminosa, pelo que evidente o maior grau de reprovação da conduta do réu e o maior risco à integridade física das vítimas, que justificam concretamente o aumento superior a 1/3.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ e o E. TJSP:

“As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de armas de fogo, por oito agentes, que agiram de forma premeditada, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das três majorantes do crime de roubo” (AgRg no HC n. 754.322/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

“presentes duas causas de aumento, a maior reprovabilidade da conduta impede a elevação na singela fração de 1/3, dado que ambas as majorantes foram decisivas

para a consumação do crime, além do que a integridade física da vítima foi efetivamente colocada em risco (...) Nessa medida, mantém-se o quantum adotado de 3/8" (TJSP; Apelação Criminal 0023293-29.2012.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021) - trecho do voto destacado.

"a pena majorada no mínimo de 1/3 para aquele que incide em apenas uma causa especial e no mesmo patamar para o agente que pratica o crime com duas causas de aumento revela situação injusta, que deve ser evitada pelo julgador" (TJSP; Revisão Criminal 2180217-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Tietê - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021) - trecho do voto destacado.

"No que tange à incidência sucessiva, no terceiro momento da dosimetria, dos aumentos previstos nos §§ 2º e 2º-A do artigo 157 do Código Penal, salienta-se, uma vez mais, que se encontra de acordo com o entendimento desta C. Câmara, sendo que tal cumulação de exasperações não implica em ofensa ao princípio da proporcionalidade, tratando-se, na verdade, de medida que apenas busca, em atenção à necessária individualização da pena, repreender mais severamente condutas revestidas de maior gravidade. A propósito: "Na última fase, a incidência das causas de aumento estabelecidas no inciso II, do § 2º (concurso de agentes) e § 2º-A (emprego de arma de fogo), com a atual redação do artigo 157, do Código Penal, já em vigor ao tempo do crime, motivaram os aumentos de 1/3 e 2/3. (...) Além disso, perfeitamente viável, no caso concreto, a aplicação dos aumentos sucessivos, tal como operado monocraticamente. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o maior rigor adotado pela novel legislação se justifica pela necessidade de se proteger não apenas o patrimônio, mas, também e com maior intensidade, a integridade física das vítimas, submetidas ao jugo de instrumento altamente vulnerante. Portanto, possível que se estabeleça o aumento de 1/3 até a metade, de acordo com as circunstâncias, pelo concurso de agentes, e a elevação fixa de 2/3, para a circunstância do emprego de arma de fogo. Vale ressaltar, ainda, 'que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado" (STF, 1ª Turma, HC 110960/DF, Relator Min. Luiz Fux, DJ 19.08.2014, sem destaques no original)" (TJSP, Apelação nº 0007812-07.2018.8.26.0635, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Juíza Claudia Lucia Fonseca Fanucchi, j. 9/5/19)." (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal nº 0001415-17.2018.8.26.0542 - Relator Desembargador Mauricio Henrique Guimarães Pereira Filho, j. 29/05/19).

Pela aplicação da regra do concurso formal, e considerando que as penas são idênticas, exaspero apenas uma delas em 1/3, totalizando onze anos, dez meses e seis dias de reclusão e pagamento de 28 dias-multa.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu DIOGO MARQUES MACHADO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por cinco vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de onze anos, dez meses e seis dias de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 28 dias multa, com unidade no mínimo legal.

Vez que condenado por delito grave e violento, o réu não faz jus a qualquer benefício.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, pela pena aplicada, pela gravidade de sua conduta e periculosidade demonstrada no curso do crime por ele praticado, não merecendo os roubadores qualquer tratamento indulgente.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

"Roubo qualificado - Regime carcerário mais gravoso - Crime grave - Conveniência de regime inicial fechado. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e a primariedade do réu, em observância com as circunstâncias presentes no fato delituoso, em conjunto com aquelas previstas no artigo 59, do Código Penal." (TJSP - 4ª Câm. de Direito Criminal - APL nº 9.211.536-56.2009.8.26.0000 - Ac. 5.335.524 - São Paulo - Rel. Desembargador Willian Campos - J. 16/08/2011 - grifei)

"Por fim, a despeito da primariedade do réu, foi bem eleito o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, sobretudo porque se trata de crime cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça, o que e recomenda enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: 'O regime prisional inicial fechado é o único adequado à espécie, em razão do montante da pena, da gravidade concreta do crime e da personalidade do agente que o prática, motivos que exigem resposta penal enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda.' (Apelação nº 0001833-19.2009.8.26.0655, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 22/06/2011)." (TJSP - 11ª Câm. de Direito Criminal - Apelação nº 0081289-43.2016.8.26.0050- Rel. Desembargador Alexandre Almeida - J. 28/02/2018- grifei).

Anote-se também o precedente do C. STJ:

"A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal" (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº 0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº 0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Ademais, de se salientar que, para a decretação e manutenção da prisão preventiva, segundo entendimento do C. STJ, é possível a utilização dos antecedentes do acusado enquanto menor de idade, aptos a demonstrar a sua periculosidade social, como é o caso dos autos, em que o réu registra atos infracionais (fls. 33):

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus commissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de



autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. No caso, forçoso convir que o decreto construtivo encontra-se fundamentado, considerando a circunstância do crime e o efetivo risco de reiteração delitiva, pois o recorrente possui registros anteriores pela prática de atos infracionais equiparados a homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, aptos a demonstrar sua periculosidade social. 3. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a prática de atos infracionais, apesar de não poder ser considerada para a fins de reincidência ou maus antecedentes, serve para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. Recurso desprovido." (STJ, 5ª Turma, RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 47.671/MS (2014/0111251-1) Relator Ministro Gurgel de Faria, j. 18/12/2014 - grifei).

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

P. R. I. C.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA